

Einleitungsartikel des ZGB

- **Anwendung des Rechts (Art.1 ZGB)**

1 Das Gesetz findet auf alle Rechtsfragen Anwendung, für die es nach Wortlaut oder Auslegung eine Bestimmung enthält.

2 Kann dem Gesetz keine Vorschrift entnommen werden, so soll das Gericht nach Gewohnheitsrecht und, wo auch ein solches fehlt, nach der Regel entscheiden, die es als Gesetzgeber aufstellen würde.

3 Es folgt dabei bewährter Lehre und Überlieferung.

Einleitungsartikel des ZGB

- Inhalt der Rechtsverhältnisse (Art. 2 ZGB) "Treu und Glauben"

1 Jedermann hat in der Ausübung seiner Rechte und in der Erfüllung seiner Pflichten nach Treu und Glauben zu handeln.

2 Der offenbare Missbrauch eines Rechtes findet keinen Rechtsschutz (vgl. Art. 336 OR). (Rechtsmissbrauchsverbot)

 *Etwas zum Schmunzeln* Lesen Sie den folgenden kurzen Artikel: [Obergericht Zürich - Nachbarschaftsstreit wegen dunkelgrüner Blache: Familie muss "Neidmauer" entfernen \(limmattalerzeitung.ch\)](#)

- Der Grundsatz von Treu und Glauben gebietet ein **loyales und vertrauenswürdiges Verhalten im Rechtsverkehr**. Der Grundsatz von Treu und Glauben beinhaltet einerseits den Vertrauensschutz, andererseits das Verbot des widersprüchlichen Verhaltens sowie das Verbot des Rechtsmissbrauchs.
 - Vertrauensschutz: Wer ein berechtigtes Vertrauen in die Redlichkeit des Gegenübers gesetzt hat, soll nicht enttäuscht werden.
 - Beispiele für Handeln gegen Treu und Glauben:
 - Ein Hauseigentümer lehnt alle vom Makler vermittelten Interessenten als ungeeignet ab. Nach der Beendigung des Maklerverhältnisses setzt sich der Eigentümer dennoch mit einem vom Makler vermittelten Interessenten in Verbindung ab, um den Abschluss zu tätigen.
 - Ein Aktionär, der einem Beschluss an der GV bereits zugestimmt hat, verhält sich treuwidrig, wenn er denselben im Nachhinein anfechtet.

Einleitungsartikel des ZGB

- Es handelt sich beim Begriff «**Treu und Glauben**» um einen **unbestimmten Rechtsbegriff**. Begriffe in diesem Zusammenhang sind anständig, redlich, aufrichtig, zuverlässig, rücksichtsvoll usw. Dieses Verhalten wird auch vom Gegenüber erwartet.
- **Rechtsmissbrauchsverbot:** Ein formelles Beharren auf einem Recht, das offensichtlich missbräuchlich erscheint, wird vom Richter nicht geschützt. Erst ein krass stossendes Verhalten (Schadenfreude, Schikane oder Rache) ist jedoch rechtsmissbräuchlich.
 - Beispiele für rechtsmissbräuchliches Verhalten: Sachenrecht
 - Der Vermieter besteht auf der Endreinigung einer Wohnung, obwohl er weiss, dass das gesamte Wohnhaus abgerissen wird. Er möchte damit einem Mieter eins auswischen.
 - Ein grundlos Enterbter wird von seinen Miterben informiert, dass sie diesem dennoch seinen Pflichtteil zukommen lassen würden, sobald die Erbmasse bestimmt sei. In der Folge verstreicht die Frist für eine Herabsetzungsklage und die Miterben machen geltend, der Enterbte erhalte nun doch nichts.

Einleitungsartikel des ZGB

- **Guter Glaube (Art. 3 ZGB)**

z.B. Lohn bei Arbeitgeber der manchmal Bonus gibt : 2000 statt 1000 zahlt und man hat es schon ausgegeben,
dann kann gutgläubiger geschützt sein.

¹ Wo das Gesetz eine Rechtswirkung an den guten Glauben einer Person geknüpft hat, ist dessen Dasein zu vermuten.

² Wer bei der Aufmerksamkeit, wie sie nach den Umständen von ihm verlangt werden darf, nicht gutgläubig sein konnte, ist nicht berechtigt, sich auf den guten Glauben zu berufen.

- Das Gesetz definiert nicht, was unter dem Begriff «**guter Glaube**» zu verstehen ist, sondern es setzt diesen voraus (vgl. Art. 24 Abs. 1 Ziff. 4 OR). Guter Glaube ist das **Fehlen des Unrechtsbewusstseins** trotz eines Rechtsmangels. «**Gutgläubig ist, wer nicht bösgläubig ist**». Bösgläubig ist, wer weiss, dass etwas Unrechtes vorliegt (Art. 64 OR).
- Es gibt keinen umfassenden Gutglaubensschutz. Dieser Artikel findet nur Anwendung, wo das Gesetz eine Rechtsfolge davon abhängig macht, ob jemand gutgläubig oder bösgläubig war.
 - Beispiele:
 - Art. 933 ZGB: Wer eine bewegliche Sache in gutem Glauben zu Eigentum übertragen erhält, ist in seinem Erwerb auch dann zu schützen, [...].
 - Art. 174 Abs. 3 ZGB: Gutgläubigen Dritten gegenüber ist der Entzug nur wirksam, wenn er auf Anordnung des Gerichts veröffentlicht worden ist. (Entzug der Vertretungsbefugnis)
 - Art. 36 Abs. 2 OR: Wird er von dem Vollmachtgeber oder seinen Rechtsnachfolgern hierzu nicht angehalten, so sind diese den gutgläubigen Dritten für den Schaden verantwortlich.

Einleitungsartikel des ZGB

- Der gute Glaube muss nicht bewiesen werden (Umkehr der Beweislast). Das Gesetz geht bis zum Beweis der Bösgläubigkeit von der Gutgläubigkeit einer Person aus.
- Für den Beweis der Bösgläubigkeit reicht aus, dass eine Person aufgrund der gesamten Umstände nicht gutgläubig sein konnte.
 - Beispiele:
 - Ein Autohändler genießt keinen Gutglaubensschutz, wenn er einen gestohlenen Ferrari gekauft hat, ohne die Fahrzeugpapiere genauer zu überprüfen.
 - Im Stadtpark wird einem von einem Fremden ein fabrikneues Handy zum Schleuderpreis angeboten.

Einleitungsartikel des ZGB

- Gerichtliches Ermessen (Art. 4 ZGB)

Wo das Gesetz das Gericht auf sein Ermessen oder auf die Würdigung der Umstände oder auf wichtige Gründe verweist, hat es seine Entscheidung nach Recht und Billigkeit zu treffen.

- Ermessen räumt einem Gericht gewisse **Freiheiten bei der Rechtsanwendung** ein (vgl. 336a Abs. 2 OR). Damit soll ein möglichst sachgerechtes Urteil gefällt werden können.

Entschädigung, dort gibt es Ermessensspielraum

- Weitere Beispiele:
 - Art. 601 Abs. 2 OR: Fehlt es an Vereinbarungen über die Beteiligung des Kommanditärs am Gewinn und am Verlust, so entscheidet darüber das Gericht nach freiem Ermessen.
 - Art. 337b Abs. 2 OR: In den anderen Fällen bestimmt der Richter die vermögensrechtlichen Folgen der fristlosen Auflösung unter Würdigung aller Umstände nach seinem Ermessen.

Einleitungsartikel des ZGB

was muss wer beweisen?
kann ich es beweisen?
Beweise: schriftlich, verhalten, Zeugen...

- **Beweisregel (Art. 8 ZGB)**

Zusammenhang mit Vertragsverletzung, die Beweislastumkehr
OR97: Schuldner muss beweisen dass er keine Schuld hat.
Kaufvertrag: Käufer muss Mangel beweisen und beweisen das schon bei Abschluss des Kaufvertrags vorhanden gewesen.

Wo das Gesetz es nicht anders bestimmt, hat derjenige das Vorhandensein einer behaupteten Tatsache zu beweisen, der aus ihr Rechte ableitet.

- Während im Strafrecht die Untersuchungsmaxime anwendbar ist, gilt im Zivilprozess i.d.R. die Verhandlungsmaxime. Ist also in einem zivilrechtlichen Rechtsstreit der zu beurteilende Sachverhalt umstritten, muss das Gericht durch Beweise (z.B. Zeugen, Gutachten, Augenschein oder Urkunden) von der Richtigkeit des behaupteten Sachverhalts überzeugt werden.
- Beispiele:
 - Der Käufer eines Fernsehers will seine Gewährleistungsrechte geltend machen. Zunächst muss er beweisen, dass er rechtzeitig die Mängelrüge getätigt hat, sofern der Verkäufer dies bestreitet.
 - Der Ehegatte der behauptet, dass er einen Vermögenswert aus Mitteln des Eigenguts gekauft habe, muss diesen Umstand beweisen.

Einleitungsartikel des ZGB

- Begriff der **Beweislastumkehr** (vgl. Art. 97 Abs. 1 OR): Zuteilung der Beweislast an eine Partei, die normalerweise nicht die Beweislast trägt.
- **Beweisnot:** Von **Beweisnot** spricht man, wenn eine Partei **eigentlich beweispflichtig** ist, es ihr aber **faktisch oder rechtlich kaum möglich** ist, den verlangten Beweis zu erbringen. Das Gericht kann in solchen Fällen die Anforderungen an den Beweis **erleichtern** (z. B. genügt Glaubhaftmachen statt strenger Vollbeweis).
 - Eine Patientin klagt einen Arzt wegen Behandlungsfehler. Sie müsste eigentlich beweisen, dass der Arzt einen Kunstfehler begangen hat. Da sie aber im Operationssaal „geistig“ nicht anwesend war und keine Fachkenntnisse hat, trifft sie eine Beweisnot.
- **Beweiserleichterung:** Das Gericht stellt an den Beweis nicht den vollen, strengen Massstab des Vollbeweises, sondern es genügen weniger strenge Anforderungen. Statt eines Vollbeweises reicht dann z. B. das Glaubhaftmachen (überwiegende Wahrscheinlichkeit).
 - Gerichte erleichtern deshalb den Beweis, indem sie etwa Behandlungsdokumentationen oder Gutachten stärker gewichten oder eine Beweislastumkehr anwenden.

Übungsaufgaben

Welcher Einleitungsartikel des ZGB ist in den nachstehenden Sachverhalten relevant:

- Roman kauft auf dem Parkplatz einer Raststätte von einer Privatperson drei Stangen Zigaretten zum halben Preis.
- Roman wurde zu unrecht fristlos entlassen. Der Richter setzt nun eine Entschädigung zwischen einem und sechs Monatslöhnen fest.
- Peter kündigt seiner Mieterin formal korrekt, nur um sie zu ärgern, da er gar nicht beabsichtigt, die Wohnung selbst zu nutzen oder weiterzuvermieten.
- Herr Müller verkauft seinem Nachbarn ein Stück Land. Im Kaufvertrag wird der Grenzverlauf ungenau eingezeichnet. Müller weiss, dass der Nachbar die Grenze missverstanden hat, schweigt aber bewusst.
- Maria behauptet, sie habe ihrem Freund Jonas 500 Franken geliehen. Jonas bestreitet dies.
- Tom kauft in einem Second-Hand-Laden eine wertvolle Uhr. Der Preis ist zwar günstig, aber nicht völlig auffällig. Später stellt sich heraus, dass die Uhr gestohlen war.
- Eine Konsumentin kauft einen neuen Laptop. Nach zwei Monaten funktioniert er plötzlich nicht mehr. Die Verkäuferin behauptet: „Der Laptop war bei der Übergabe in Ordnung, Sie müssen ihn unsachgemäss behandelt haben.“
- Ein Schreiner verpflichtet sich vertraglich, für die Kundin Sophie bis zum 1. Mai einen Esstisch zu liefern. Der Tisch wird nicht geliefert. Sophie verlangt Schadenersatz für die Kosten, die ihr durch die Miete eines Ersatzmöbels entstanden sind. Der Schreiner sagt: „Ich konnte den Tisch wegen einer plötzlichen Holzknappheit nicht rechtzeitig fertigstellen, daran bin ich nicht schuld.“